

刑法

No50

H29-3

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、乙を殺害する目的で、乙を含む複数の者の飲用に供されているペットボトル内のお茶に致死量の劇薬を投入した。その結果、そのお茶を飲用した複数の者全員が死亡した。この場合、甲には、前記お茶を飲用して死亡した者の数に応じた殺人罪の故意が認められる。
- イ. 覚せい剤を含有する粉末を所持していた甲は、同粉末が身体に有害で違法な薬物であることは認識していたが、覚せい剤や麻薬ではないと認識していた。この場合、甲には覚せい剤取締法違反（覚せい剤所持）の罪の故意が認められる。
- ウ. 甲は、客観的にはわいせつな文書を、その意味内容は理解しつつも、刑法上のわいせつな文書に該当しないと考え、多数の者に販売した。この場合、甲にわいせつ物頒布罪の故意は認められない。
- エ. 甲は、乙宅前路上に置かれていた自転車を、乙の所有物と認識して持ち去ったが、実際には同自転車は無主物だった。この場合、甲には遺失物横領罪が成立する。
- オ. 甲は、第三者が起こした交通事故により瀕死の重傷を負い路上に倒れていた乙を、既に死亡していると思って山中に遺棄した。この場合、甲に死体遺棄罪は成立しない。
1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ オ 5. ウ エ

No50

故意

正答率

H29-3

正解

2

77%

ア 正しい

最判昭53.7.28(百選I42事件)は、本記述と類似の事案において「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもつて足りるものと解すべきである……から、人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかつた人に対してその結果が発生した場合にも、右の結果について殺人の故意があるものというべきである。」としている。この判例は、法定的符合説のうち数故意犯説をとったものであると評価されている。本記述においては、甲は乙という人を殺害する意思の下にペットボトルに致死量の劇薬を入れるという殺害行為に出たところ、乙だけでなく、ペットボトル内のお茶を飲用した複数の者全員が死亡している。よって、甲には、生じた複数の者の死亡の数に応じた殺人罪の故意が認められる。

イ 誤っている

最決平2.2.9(百選I40事件)は、覚せい剤輸入罪の故意が認められるために、行為者にどの程度の認識が必要かが争われた事案において、「被告人は、本件物件を密輸入して所持した際、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる。そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはない」としている。しかし、判例の結論に賛成する学説であっても、覚せい剤や麻薬の認識が排除されている場合には故意が否定されると解している。本記述においては、甲は自己が所持していた粉末を覚せい剤や麻薬ではないと認識していた以上、甲に覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪の故意は認められない。

ウ 誤っている

最大判昭32.3.13(百選I47事件)は、本記述と同様の事案において、「刑法175条(現175条1項)の罪における犯意の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要としているものでない。かりに主観的には刑法175条(現175条1項)の猥褻文書にあたらないものと信じてある文書を販売しても、それが客観的に猥褻性を有するならば、法律の錯誤として犯意を阻却しないものといわなければならない。」としている。規範的構成要件要素の認識について、①裸の事実の認識(その文書に記載されている文章の存在の認識)、②意味の認識(当該文章の持つ社会的意味の認識)、③あてはめの認識(その文書が175条1項の「わいせつ」に当たるという認識)に分けることができる。上記判例は、このうち、少なくとも③の認識は不要であるとしたものであると解されている。本記述においては、甲は客観的にはわいせつな文書の意味内容を理解した上で、その文書を多数の者に販売しているため、①・②の事実認識はある。よって、刑法上のわいせつな文書に該当しないと考えていても、甲にわいせつ物頒布罪の故意は認められる。

エ 誤っている

254条。遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。条文上、遺失物横領罪の客体は他人の物であることが要求されているため、無主物は同罪の客体にはならない。本記述においては、自転車が無主物であるため、遺失物横領罪の客観的構成要件を欠く。よって、同罪は成立しない。

オ 正しい

本記述において、乙は死亡していないため、甲は「死体」を「遺棄し」たといえず、死体遺棄罪（190条）の客観的構成要件に該当しない。もっとも、甲は乙を遺棄しており、単純遺棄罪（217条）の客観的構成要件に該当し、主観的には死体遺棄罪（190条）の故意が認められる。そこで、抽象的事実の錯誤として死体遺棄罪の限度で犯罪が成立するか問題となる。この点、認識・予見した事実と実際に発生した事実とが構成要件の範囲内において重なり合っている場合に、実際に発生した構成要件該当事実について故意を肯定する立場（法定的符合説）から、抽象的事実の錯誤について両罪の構成要件に実質的な重なり合いがある場合に故意を肯定するのが判例である（最決昭54.3.27）。本記述において、甲が実現した単純遺棄罪と、認識していた死体遺棄罪とは、遺棄という実行行為においては共通している。しかし、通説によれば、単純遺棄罪の保護法益が生命・身体の安全であるのに対して、死体遺棄罪の保護法益は、国民の宗教感情及び死者に対する敬虔・尊崇の感情であるとされている。したがって、保護法益が異なり、両罪の構成要件に実質的な重なり合いは認められないため、死体遺棄罪の成立は認められない。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。